

1500263-25.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo os entorpecentes acima mencionados para facilitar a entrega aos usuários. Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro em operação visando o combate ao tráfico de drogas, intenso naquele local. Assim, ao se aproximarem com a viatura próxima da viela que dá acesso à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500263-25.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050619/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23170955 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 440/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2050619 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

OTAVIO LEITE MARTINS

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

03/06/2022

Réu Preso

Em 03 de junho de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu OTAVIO LEITE MARTINS, bem como o seu Defensor Técnico, DR. João Pedro de Oliveira Masson OAB 94899/RS. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Evandro Domingues Simões (PM) e Jenifer Iasmin Soares do Prado. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foi ouvida a testemunha Evandro Domingues. Ato contínuo, o representante do Ministério Público disse: "Diante da informação que a testemunha Otniel Barta da Silva encontra-se de férias regulamentares (fls. 161), bem como a menção pelo Policial Evandro de que teria participado da diligência o Policial Militar Danilo Dias de Miranda, requereiro de Vossa Excelência a substituição da testemunha Otniel pelo Policial Militar

Danilo Dias de Miranda, tentando-se contato para que sua oitiva ocorra ainda neste ato". Tendo o Defensor se manifestado contrariamente ao quanto postulado pelo membro do Parquet, pela MMª Juíza de Direito foi dito: "Defiro o quanto requerido pelo Ministério Público, pois não vislumbro prejuízo à ampla defesa do acusado. Proceda-se a serventia contato com o Batalhão da Polícia Militar de Tatuí a fim de que se verifique a possibilidade da oitiva do Sargento Danilo Dias de Miranda, ainda neste ato". Após alguns instantes, tendo ingressado na sala virtual o Policial Militar Danilo, procedeu-se a sua oitiva, passando-se logo após a oitiva da testemunha Jenifer Iasmin e, por fim, ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu OTAVIO LEITE MARTINS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 00h10, na Rua Antônio Orlando Salmasi, nº 486, Vila Vicente Correa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 44 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 85,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como que o acusado concorreu para essa ação criminosa, solicitando o envio da droga. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo os entorpecentes acima mencionados para facilitar a entrega aos usuários. Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro em operação visando o combate ao tráfico de drogas, intenso naquele local. Assim, ao se aproximarem com a viatura próxima da viela que dá acesso à linha férrea, visualizaram o denunciado que, por sua vez, ao avistar a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga e, enquanto corria, jogou uma sacola de plástico em um mato próximo ao local, porém foi perseguido e abordado. Em revista pessoal, em poder de OTAVIO, foi localizada a quantia de R\$ 125,00 em espécie e, ao verificar o que havia jogado antes da abordagem, verificou-se tratar de uma sacola contendo 44 porções de maconha. O réu foi notificado (fls. 117) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 132/140). Assim, por decisão proferida no dia 19 de maio de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 142/147). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatório, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 29/38, bem como Certidões a fls. 24/28. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente consigno pela ausência de prejuízo a ampla defesa, quanto a substituição da testemunha Otiniel Barta da Silva, em gozo de férias, pela testemunha Sargento Miranda. A defesa insurgiu-se pela nulidade no ato de audiência, embora não o tenha deduzido em alegações finais. Tem-se que para efetividade do ato, a fim de encerrar-se a instrução, requereu o órgão acusatório a substituição da testemunha ausente por outra, Sargento Miranda, cuja participação na diligência policial relacionada aos fatos fora descrita pelo policial Evandro, ouvido nesta data. Assim, a serventia contactou o Sargento Miranda, que se disponibilizou para o ato. Não vislumbro prejuízo algum na substituição da testemunha, ainda que não se trate de policial

apontado no boletim de ocorrência, eis que a praxe policial é que apenas dois policiais apresentem a ocorrência, retornando os demais ao patrulhamento. Ademais, como se verá, o próprio réu fez alusão a testemunha Sargento Miranda. Em relação a preliminar de nulidade deduzida em sede de defesa prévia, quanto a suposta quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova produzida sobre as drogas apreendidas nos autos, a matéria já fora apreciada em decisão de fls. 142/147. Mas oportuno, consignar, ainda que não tenha sido objeto de alegações finais orais, que o próprio C. STJ julga: "Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022). Como se vê, não foram traçadas balizas normativas para dimensionar as consequências jurídicas da atipicidade procedimental da cadeia de custódia. E, portanto, conforme julga o C. STJ: "Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022). Em síntese, nem toda atipicidade procedimental da cadeia de custódia conduz a imprestabilidade da prova produzida, devendo ser perquirido a intensidade do desrespeito ao modelo típico legal e se houve eventual comprometimento de sua eficácia probatória, em análise conjunta com os demais dados de prova produzidos. Com essa premissa estabelecida, observo que, realmente, há falta de documentação no que tange a "fixação" do vestígio (art. 158, inciso III, do CPP). Entretanto, a despeito de não se revestir de forma documental, a "descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames" (art. 158, inciso III, do CPP) foi realizada por meio de prova oral, em especial dos depoimentos dos Policiais Militares. Esses agentes públicos, cujo valor probatório de seus depoimentos não se distinguem de qualquer outra testemunha, afirmaram com suficiente precisão o local de apreensão de drogas. Não há, portanto, a despeito da falta de documentação nos autos, provas de comprometimento da cadeia de custódia. Pelo contrário, há provas de foi respeitado, na maior medida possível, o procedimento de cadeia de custódia, pois os policiais militares relataram que, tão logo suspeitaram que as substâncias dispensadas pelo réu eram drogas, adotaram comportamentos tendentes a apreender e coletar o material, descrevendo, de forma mais minuciosa possível, a localização do entorpecente. Logo em seguida, os objetos apreendidos foram entregues à Polícia Civil, que lavrou o competente auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), bem como o auto de constatação preliminar (fls. 07), descrevendo as drogas de forma minudente e o acondicionamento de forma prevista pela Lei nº 11.343/06. Ao término dessa etapa, com lacre para garantir a inviolabilidade do material apreendido, remeteram ao competente setor de perícias. Nesse setor, o material coletado chegou acondicionado em embalagem plástica transparente e inviolado, pela ausência de rompimento do lacre. Assim, foi produzida a prova pericial questionada através de métodos científicos, seguindo a metodologia apropriada e apresentando a devida conclusão pericial, sendo, tudo isso, documentado em laudo pericial (fls. 109/112). Como se vê, não houve nenhuma desobediência à cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) capaz de macular a conclusão pericial ou induzir dúvida a respeito do que foi atestado pelos peritos. Dito de outro modo, se houve atipicidade procedimental (não documentação da "fixação" dos vestígios), essa não foi suficiente a comprometer a prova produzida sobre esse elemento coletado. E se não há prejuízo, não há nulidade, conforme preceitua o art. 563 e 566, ambos do CPP, que dispõe, respectivamente e in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" e "Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa". A propósito, assim se posiciona o C.

STJ: "A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief." (AgRg no RHC 153823/RS, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021). Afastada a questões preliminares suscitada, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência dos fatos narrados na exordial, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/112) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 11), o réu manteve-se silente. Em juízo, disse que é um cara trabalhador, tem 03 filhos e no dia dos fatos estavam comemorando 03 anos de namoro. Chegou as 18 horas, tomou um banho, começou a comemorar com ela, seu pai e seus filhos, acabou a cerveja ele pegou o dinheiro e saiu. Quando se encontrava numa adega que vende bebida, sendo que se lembrava só daquele lugar que estaria aberto, foi abordado pelos policiais, que indagaram seu nome, se tinha passagem, começaram a xingá-lo, que ele tinha corrido, disse que estava ali atrás de bebida. Não chegou nem a pegar bebida, e foi agredido com tapas e chutes, ofendido. Mora no bairro Santa Cruz mas por ser segunda feira as 23 horas, não havia nenhum estabelecimento aberto, por isso foi até o bairro Rosa Garcia, nessa Adega. Não conhecia esses policiais. Nem conseguiu correr, quando saiu da viela, já foi abordado. Acredita que os policiais o imputaram essa droga porque ele tinha passagem. Já tinha uma movimentação dos policiais com outros indivíduos, mas não sabe o que aconteceu com eles. Tem passagem anterior por tráfico e já teve passagem na vara da infância e juventude. Não o deixaram prestar depoimento na delegacia. Perguntas da defesa – sua cor é parda, como está na sua certidão de nascimento. Confirma que declarou as agressões para o medico perito, que foi agredido, que apertaram sua garganta, que levou uma chave de braço e desmaiou. Só acordou na delegacia. O último policial que foi ouvido aqui, lhe agrediu, disse que ele era um trouxa por segurar a droga. Que ele também o abordou. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou os fatos. Em relação ao relato de suposta agressão por parte dos milicianos, o fato já fora apreciado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia que em decisão de fls. 49, determinou fossem apurados os fatos. Quanto ao mérito, eventual abuso cometido pelos policiais, segundo alegação do réu, não afasta a prova de sua autoria, e a versão do réu de que estaria em bairro totalmente diverso do seu, distante, para comprar cerveja, quase meia-noite, sendo injustamente incriminado pelos policiais por ter antecedentes criminais, mostra-se frágil e inconsistente. Vejamos: De outro lado, o Policial Militar Evandro Domingues Simões, em sede policial (fls. 08/09), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento, deslocaram-se com as demais viaturas até o bairro Rosa Garcia II, no intuito de combater o tráfico de drogas no local. Realizado o cerco pelo bairro e quando aproximaram com a viatura da viela que dá acesso a linha férrea, visualizaram um indivíduo, que posteriormente identificado como OTÁVIO LEITE MARTINS, no começo da viela. Então, ao visualizar a viatura, o acusado empreendeu fuga viela a dentro, sendo acompanhado de perto pela equipe. A todo momento, ele mantinha a mão esquerda segurando algo na cintura e, ao perceber que seria abordado, dispensou uma sacola em um mato. Em seguida, foi abordado e em revistado, oportunidade em que foi localizada a quantia de R\$125,00 com ele. Ao retornar para verificar o que o acusado havia jogado antes da abordagem, obtiveram êxito em localizar uma sacola contendo 44 porções de substância análoga a maconha. Instado, o acusado negou a mercancia no local. Em juízo, disse que foi determinada uma operação pelo Sargento Miranda eis que havia muitas reclamações de moradores acerca do trafico de drogas no bairro. Quando estavam em patrulha pelo bairro, o réu ao

avistar a viatura próximo a linha férrea, empreendeu fuga e jogou algo, que depois apurou-se ser uma sacola plástica com 44 porções de drogas. Não conhecia o acusado, mas em pesquisa em seu RG verificou-se várias passagens pelo sistema, inclusive pelo tráfico de drogas. O réu estava calmo no momento da abordagem, mas na delegacia ele ficou alterado. O local é de baixa iluminação, mas no local que encontraram o réu há iluminação pública. Não visualizaram outras pessoas com o réu. O réu negou a mercancia ilícita e a propriedade da droga. O policial Barta e o Sargento Miranda visualizaram com clareza o réu dispensar a droga, tanto é que a encontraram rapidamente no mato. Ouvido nesta oportunidade o Sargento Danilo Miranda, eis que, dada a impossibilidade de oitiva nesta data do policial Otniel Barta, por gozo de férias, foi requerida a substituição pela testemunha referida, o ora depoente, uma vez que a testemunha Evandro relatou que o Sargento Miranda participou da diligência, este as perguntas da acusação declarou: "É uma prática comum que conste dois policiais para registrar a ocorrência e os demais sigam no patrulhamento na cidade. Disse que estavam em patrulhamento pelo bairro, com alto índice de tráfico, o réu ao avistar a viatura saiu correndo e dispensou algo. Em abordagem pessoal encontraram com o réu dinheiro e ao verificarem o percurso feito pelo réu, voltaram ao local que o réu havia dispensado a sacola e nesta sacola se encontravam os entorpecentes". As perguntas da defesa disse - Foi ele e policial Barta que correram atrás do réu. Está de folga hoje, não estava no mesmo local que o policial Evandro. Ajudou na revista pessoal do réu. Perguntas do juízo - foi muito nítido quando o réu dispensou a sacola, tanto é que viram que ele tentava tirar algo e pensaram que poderia ser uma arma, mas era a sacola. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). A depoente Jenifer Iasmim, esposa do réu, foi ouvida sem compromisso, disse que no dia dos fatos o réu trabalhou fazendo bico de servente, chegou umas seis horas, comemoraram o aniversário de namoro e por volta das onze e meia da noite ele saiu para comprar mais cerveja e cigarro. Quando acordou achou que o réu tinha saído para trabalhar e a tarde ficou sabendo que ele foi preso. Ele não saiu com sacola na mão. Ele fuma maconha, mas não em casa. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes depoimentos dos policiais, que narraram verossimilmente, a apreensão de drogas que o acusado dispensou; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/112), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação

múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de quaisquer instrumentos ou apetrechos para a utilização da droga; e 4) o comportamento altamente suspeito do réu, que estava em ponto de tráfico de drogas e, ao visualizar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, dispensando o entorpecente no trajeto. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334,

170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 109/112) e demonstrado que o réu concorreu para a execução de verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrado o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes traçadas no artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu. De fato, deve-se ser considerado nesse momento que o réu ostenta diversas condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e as outras a agravante de reincidência sem que se incorra em bis in idem, conforme jurisprudência do C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Desse modo, considerarei a condenação definitiva operada nos nº 0010093-13.2011.8.26.0624 (fls. 27), como maus antecedentes. Por tal motivo, fixo sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, faz-se presente a circunstância agravante de reincidência (fls. 25/26 – Proc. 0001507-50.2012.8.26.0624; fls. 26 – Proc. 0003635-67.2017.8.26.0624; e fls. 27/28 – Proc. 0013655-93.2012.8.26.0624) agravo novamente sua pena em 1/6, fixando-se a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680(seiscentos e oitenta) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Por fim, tem-se que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se trata de réu reincidente e de maus antecedentes, não estando, assim, preenchidos todos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da benesse, que reclama primariedade e bons antecedentes. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e no artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, posto que se

trata de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. A mesma motivação acima

exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu OTAVIO LEITE MARTINS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente específico e com maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 141), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 96) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 125,00 em dinheiro - fls. 115) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência crimínosa. Por derradeiro, consigno que o relato de agressão do réu por parte dos policiais militares, já fora objeto de providências pelo MM. Juiz da Custódia, em decisão de fls. 49". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e contrarrazões de apelação, remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA